

1500005-97.2020.8.26.0631

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... havido comprovação suficiente acerca do tráfico de drogas, não obstante a apreensão dos entorpecentes. Deste modo, opinou pela desclassificação do crime de tráfico para a posse de drogas (artigo 28 da Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, em alegações finais, a defesa do acusado ratificou o parecer do Ministério Público, pleiteando a desclassificação do crime.

É O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

2ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500005-97.2020.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500005-97.2020.8.26.0631

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOHNNY FERRETI LEMES e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra ISABELA DE CARVALHO CANDIDO e JOHNNY FERRETI LEMES, já qualificados, dando-os como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 78-79):

"Consta dos inclusos autos que, no dia 02 de janeiro de 2020, na Avenida Orlando Audrai Barros Bueno, nº 271, Conj. Habitacional Alberto Marques, Centro, nesta cidade e comarca de Amparo, ISABELA DE CARVALHO CANDIDO, qualificada às fls. 06, e JOHNNY FERRETI LEMES, qualificado às fls. 07, agindo em unidade de desígnios entre si, guardavam 19 (dezenove) porções de cocaína, pesando aproximadamente 39g (trinta e nove gramas), 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 5g (cinco gramas) e 7 (sete) pedras de crack, pesando aproximadamente 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme consta dos autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 13/14 e 15/16".

Os acusados foram devidamente notificados (fls. 111 e 204) e apresentaram suas respectivas defesas preliminares (fls. 116 e 216-223). A denúncia foi formalmente recebida em 13 de janeiro de 2022 (fls. 243-244). No decorrer da instrução processual foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, a ré ISABELA foi interrogada.

No que concerne ao réu JOHNNY, vieram notícias acerca do seu falecimento (fl. 258) – o que restou confirmado após a juntada da certidão de óbito (fl. 269). Em razão disso, julgou-se extinta a punibilidade de JOHNNY FERRETI LEMES, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal (fl. 270).

Como consequência, a presente ação penal somente prosseguirá em face da ré ISABELA, embora venha a mencionar ocasionalmente o corréu falecido.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, entendeu não ter havido comprovação suficiente acerca do tráfico de drogas, não obstante a apreensão dos entorpecentes. Deste modo, opinou pela desclassificação do crime de tráfico para a posse de drogas (artigo 28 da Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, em alegações finais, a defesa do acusado ratificou o parecer do Ministério Público, pleiteando a desclassificação do crime.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede integralmente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 10-12), auto de exibição e apreensão (fls. 13-14), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15-16), fotografias das drogas (fls. 19-21) e, especialmente, pelos laudos químico-toxicológicos (fls. 89-97).

A autoria é igualmente certa e recai sobre a acusada, apesar de suas negativas apresentadas em Juízo.

Vale ressaltar, desde já, que “nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição” (artigo 385 do Código de Processo Penal). Quanto ao caso dos autos, reputo haver elementos firmes e convincentes acerca do narcotráfico – com a devida vênia ao entendimento ministerial diverso.

Consta dos autos que, na data dos fatos, uma equipe da polícia militar promovia um patrulhamento preventivo pelo Bairro São Dimas, notadamente nas proximidades da avenida principal – onde costuma ser intenso o comércio ilícito de entorpecentes. Em dado momento, ao passarem diante de um prédio em construção – onde já foram realizadas prisões envolvendo o narcotráfico –, os agentes policiais perceberam quando um sujeito saiu do imóvel em questão. Tratava-se de JOHNNY (feito extinto), indivíduo já conhecido nos meios policiais como traficante.

A primeira reação de JOHNNY, ao perceber a presença da equipe, foi se virar e retornar à construção – o que, evidentemente, chamou a atenção dos policiais. Estes deixaram a viatura imediatamente e saíram em perseguição ao suspeito. Os agentes chegaram a tempo de ver JOHNNY escondendo algo em uma brecha da parede.

De fato, após a abordagem, os policiais recuperaram o invólucro que foi escondido, o qual trazia em seu interior 07 pedras de “crack”, 04 pinos de cocaína e 01 bucha de “maconha” – tudo devidamente embalado e pronto para a comercialização. Ato contínuo, e sabendo que o prédio em questão possuía um andar superior, os policiais solicitaram apoio de reforços e subiram.

No segundo andar se encontrava a ré ISABELA (na época, companheira de JOHNNY), a qual simulou estar dormindo em um colchão. Realizada a abordagem, os policiais levantaram o colchão e lá encontraram um pacote contendo 15 pinos de cocaína – embalados de maneira idêntica àquelas porções escondidas por JOHNNY (conforme se verifica pela fotografia de fl. 21).

Importante ressaltar que só havia o casal no interior do prédio. Além disso, o pacote contendo os entorpecentes estava escondido em meio aos pertences pessoais de ISABELA, incluindo roupas, bolsa e até peças íntimas. Ao serem conduzidos à Delegacia, JOHNNY e ISABELA admitiram que estavam desempregados (conforme fls. 17 e 22).

Estevão Cassiano Cimenton, policial militar, prestou um detalhado depoimento em Juízo, confirmando os fatos narrados acima. Explicou que, na ocasião, efetuavam um patrulhamento pela principal avenida do bairro. Em dado momento, passaram em frente a uma construção, a qual é bastante utilizada como “ponto de tráfico”. Enquanto passavam, perceberam o JOHNNY saindo da construção. Porém, ao perceber a viatura, ele retornou rapidamente para o interior. Em vista disso, desembarcaram e o seguiram, chegando a tempo de vê-lo escondendo um maço de cigarro em um buraco da parede. JOHNNY foi abordado e o maço de cigarro continha porções de “crack”, “maconha” e cocaína, além de moedas. Ato contínuo, solicitaram apoio e subiram ao segundo andar da construção, onde encontraram ISABELA deitada em um colchão e fingindo estar dormindo. Realizada a abordagem, levantaram o colchão e, em meio aos pertences pessoais da ré (incluindo roupas íntimas) havia 15 pinos de cocaína – idênticos àqueles apreendidos com o JOHNNY.

Cristiano Roberto Cimenton, também policial militar, corroborou integralmente os relatos do seu parceiro de farda – não apresentando qualquer contradição ou incoerência.

Importante ressaltar que as narrativas dos agentes policiais não se alteraram desde a fase inquisitiva, não havendo nos autos qualquer indicativo de que possuíssem desavenças anteriores com os acusados. Em vista disso, e estando confirmados por outros meios de prova, tais relatos devem ser acolhidos com credibilidade. Sobre o tema, há entendimento solidificado nos Tribunais Superiores:

“Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ – HC 408808/PE, 5ª T., rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 03.10.2017).

E ainda:

“É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ – HC 393516/MG, 5ª T., rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.06.2017).

Todavia, não obstante a clareza das provas, ISABELA optou por negar o crime de tráfico em seu interrogatório judicial. Alegou que, na data dos fatos, estava na construção junto a outras três pessoas: o JOHNNY (seu companheiro), o “Cabelo” e o “Biel”. Em dado momento, o JOHNNY e o “Biel” saíram para buscar mais entorpecentes, a fim de usarem. Eles, porém, foram abordados pela polícia na rua. Um dos policiais subiu na construção e chegou ao local em que estava junto ao “Cabelo”. Ele indagou sobre onde estaria a droga, momento em que ISABELA reconhece ter mostrado um esconderijo na parede. Afirma ter explicado ao policial que, embora soubesse o esconderijo, não estava envolvida com o tráfico. Posteriormente, ISABELA alega ter sido colocada junto aos outros, enquanto o policial fazia a varredura na construção. Ele encontrou um pacote com pinos de cocaína e foi perguntar a quem pertencia, mas ninguém assumiu. Neste momento, o “Biel” pediu para falar em particular com um dos policiais e, pouco depois, os agentes voltaram e prenderam ela e o JOHNNY – soltando os outros dois. Indagada sobre o que faziam no local, ISABELA alegou que os outros, incluindo seu companheiro, vendiam drogas, enquanto ela só estava ali para fazer o uso de “crack”.

Referida versão, entretanto, não encontra qualquer suporte no contexto fático-probatório constante dos autos. Ora, é bastante conveniente à acusada alegar (sem provas) que todos os outros eram traficantes – menos ela própria, embora estivesse desempregada e não possuísse recursos para justificar a compra de drogas.

Não parece plausível que os policiais tenham escolhido aleatoriamente quem iriam acusar e quem iriam “liberar”. Aliás, em Juízo ISABELA alegou que os outros sujeitos presentes na construção se chamavam “Biel” e “Cabelo”. Já na fase inquisitiva, alegou que os entorpecentes eram de responsabilidade de um tal Robson, vulgo “Rô”, mas que ele não estava presente por ocasião da incursão policial – não

fazendo qualquer menção a “Biel” ou “Cabelo”.

A defesa técnica e o próprio Ministério Público manifestaram, ao final, o entendimento de que os entorpecentes apreendidos pelos policiais se destinavam ao consumo próprio da acusada. Entretanto, isto não faz qualquer sentido se considerarmos a versão da própria ISABELA, a qual mencionou que é usuária somente do “crack” (fl. 22). Frise-se que os entorpecentes localizados entre seus pertences pessoais não eram porções de “crack”, mas de cocaína.

De todo modo, vejamos o que diz o artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Pois bem. Analisando cada um destes fatores, resta claramente demonstrado que os entorpecentes não possuíam destinação ao consumo próprio, mas sim ao repasse a terceiros. Com efeito:

- a) Quanto aos entorpecentes: existiam porções de três espécies distintas (“crack”, “maconha” e cocaína), todas elas embaladas e prontas para a venda. Ressalte-se que a própria ISABELA reconheceu que o seu companheiro também vendia drogas, e ele foi flagrado escondendo porções idênticas àquelas que ela guardava sob seu colchão;
- b) Quanto ao local: conforme frisado por ambos os policiais militares, o local era um conhecido ponto de tráfico. A ré também acabou reconhecendo isso ao mencionar que os outros sujeitos estavam no local para vender drogas;
- c) Quanto às condições da abordagem: ISABELA, que possuía residência fixa em outro bairro (conforme fl. 22), foi encontrada em uma construção alheia, deitada sobre um colchão e fingindo estar dormindo em pleno dia (cerca de 09h00). Era clara a suspeita de que poderia estar escondendo algo no local. De fato, a maior parte dos entorpecentes foi localizada em meio aos seus pertences pessoais. A outra parte, estava com seu companheiro;
- d) Quanto às circunstâncias pessoais: a acusada admitiu na Delegacia que não possuía emprego. Mais do que isso, afirmou que nunca trabalhou (fl. 22). Seu companheiro também não estava trabalhando (fl. 17). Ainda assim, ISABELA não demonstrou satisfatoriamente onde obtinham dinheiro para consumirem entorpecentes no local.

Não é preciso flagrar o momento exato da venda do entorpecente para concluir que a droga possuía tal destinação. Em verdade, há determinadas situações em que a soma de todos os indícios aponta claramente para a ocorrência do crime. Neste sentido, convém mencionar o artigo 239 do Código de Processo Penal: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

Ressalte-se que não se deve confundir os conceitos de indício e presunção. Esta última, de fato, não constitui um meio de prova válido, na medida em que se trata de mera opinião ou suspeita, fundamentadas em suposições abstratas. Por outro lado, o indício é o elemento obtido através de uma análise comparativa entre as provas diretas, que “(...) possibilitam atingir o estado de certeza no espírito do julgador” (Bento de Faria, Código de Processo Penal, v. 1, p. 349-350).

De fato, a grande maioria dos crimes não deixam provas absolutas de toda a execução por parte do criminoso, de modo que o magistrado necessita colher tudo o que está ao alcance, proceder a comparações, retirar contradições, confirmar com depoimentos e, através de um método indutivo (que não se confunde com “dedutivo”), chegar à verdade processual definitiva, seja para uma condenação ou absolvição.

Não fossem possíveis o método indutivo e a utilização dos indícios, não haveria o princípio da livre apreciação da prova pelo juiz e a apuração criminal se extinguiria em toda a sociedade. É isso o que leciona o ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“(…) Os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação, quanto para a absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descuidar que há muito preconceito contra essa espécie de prova, embora seja absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la. Nem tudo se prova diretamente, pois há crimes camuflados – a grande maioria – que exigem a captação de indícios para a busca da

verdade real" (Código de Processo Penal Comentado, 12ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 553).

É através dos elementos indiciários e do método indutivo que o Poder Judiciário pode condenar o criminoso, mesmo quando houver eventual ocultação do cadáver ou destruição da arma do crime. É neste sentido o entendimento jurisprudencial:

"Penal. Furto duplamente qualificado, na forma tentada. Condenação criminal imposta em primeira instância. Defesas dos acusados apelam em busca da absolvição.

Impossibilidade. As circunstâncias indicam envolvimento dos réus nos fatos. (...) Crime ordinariamente executado às ocultas, sendo, por isso, suficiente para a

comprovação da autoria a presença de simples prova indiciária" (TJSP - Apelação nº 0031914-81.2015.8.26.0576, 9ª Câmara de Direito Criminal, rel. Souza Nery, j. 03.08.2017).

E ainda:

"Apelação criminal. Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma. Irresignação bilateral. Recurso ministerial visando à condenação da corré absolvida em primeira instância. Procedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas no curso da instrução criminal. Prova segura que dá arrimo ao anelo acusatório. A jurisprudência pátria reconhece, ademais, o valor da prova indiciária, nos moldes do art. 239 do Código de Processo Penal. Condenação Decretada" (TJSP - Apelação nº 3044591-52.2013.8.26.0224, 8ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Euvaldo Chaib, j. 01.08.2017).

Anote-se, ademais, que a defesa técnica não promoveu a juntada de qualquer prova, nem arrolou testemunhas para sustentar sua versão.

Por fim, analisando as circunstâncias acerca da aplicação da pena, verifico que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da figura privilegiada prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Com efeito, a ré não possui condenação criminal (conforme fl. 51) e não há informações seguras a indicar sua dedicação a atividades criminosas. Tais elementos demonstram, ao menos em aparência, que a traficância foi algo pontual na vida da acusada. Quanto à diminuição, não vejo óbice a que ocorra no patamar máximo, isto é, em 2/3 (dois terços).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR ISABELA DE CARVALHO CANDIDO como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, passo a dosar as penas, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes, tecnicamente. Não existem dados suficientes para se aferir sua personalidade. O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou a confirmação exata do tempo em que se comercializavam as drogas.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, vez que a ré possuía menos de 21 anos na data dos fatos. Contudo, deixo de atenuar a pena, vez que ela já se encontra em seu mínimo legal - em conformidade com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Verifico, no presente caso, a hipótese de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Levando em consideração a fundamentação exposta no corpo da sentença, diminuo a pena em 2/3 (dois terços).

Tendo em vista a inexistência de causas de aumento, torno definitiva a pena da acusada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do disposto no artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, e levando-se em

consideração o atual entendimento dos Tribunais Superiores, a ré poderá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, anteriormente dosada, em regime aberto. Haja vista os termos da Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, bem como o entendimento firmado pelo STF nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, é cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, nos casos em que for aplicado o privilégio do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

No caso dos autos, verifico que a ré preenche todos os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal, de modo que a substituição da pena se revela suficiente à repressão do delito.

Assim sendo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo a ser destinada a alguma instituição assistencial, a ser escolhida pelo d. Juízo da execução, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, como forma de que a sentenciada compreenda o caráter ilícito de sua conduta.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade em face do teor da presente sentença, vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Quanto ao numerário apreendido na ocorrência (R\$ 7,75), tendo em vista ser fruto do tráfico, determino o seu perdimento em favor da União, devendo a serventia providenciar a necessária transferência à SENAD após o trânsito em julgado da condenação. O comprovante de depósito do valor encontra-se juntado à fl. 86.

Expeçam-se as devidas certidões de honorários aos patronos nomeados pelo convênio DPE/OAB, na proporção dos serviços prestados (fls. 113 e 213).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- a) Expeça-se a guia de execução da ré.
- b) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação da ré, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- c) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação da ré.
- d) Oficie-se à SENAD, nos termos do artigo 63, §4º, da Lei 11.343/06.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Amparo, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA